

1501069-12.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/08/2022
... Justiça deste estado:

"HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501069-12.2019.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501069-12.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2292684/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 7855210 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1869/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FIGUEIRA DO NASCIMENTO DA SILVA RIZATO

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de , qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 14 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03; conforme exordial acusatória (fls. 63/64).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2019 (fls. 67/68). O réu apresentou sua resposta à acusação (fls. 69/71), por meio do seu defensor constituído (fls. 72/73).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas e as informantes judiciais. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais por meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela integral procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. Requereu, ainda, a prisão preventiva do acusado (fls. 220/231).

Por sua vez, a defesa pleiteou a improcedência da pretensão punitiva. Preliminarmente, suscitou o cerceamento de defesa, pelo indeferimento na perícia do celular apreendido com o acusado. No mérito, alegou carência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; a fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa por restritivas de direito; a restituição do aparelho celular; a concessão da gratuidade de justiça; e a concessão do apelo em liberdade (fls. 235/258).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Após apresentação de sua derradeira peça, a defesa requereu a conversão do julgamento em diligência para atualização da certidão de objeto e pé do processo nº. 127150-20.2018.8.26.0625, com a concessão de novo prazo para aditamento das alegações finais (p. 265).

Contudo, não é caso de deferimento, já que o processo mencionado consta da certidão de fls. 261/262, não havendo até o presente momento nova movimentação relevante da referida ação penal a justificar a atualização da certidão, ou mesmo a juntada de certidão de objeto e pé específica de tal feito.

Com relação à preliminar invocada, malgrado respeito destinado ao nobre defensor, igualmente não é o caso de acolhê-la.

Com efeito, o deferimento da requisição de perícia no celular apreendido apenas retardaria o desfecho dos autos, sem maior auxílio no esclarecimento dos fatos.

Conforme se verá à frente por ocasião da análise das provas orais e da autodefesa do réu, não há qualquer menção ao aparelho celular ou às conversas e informações eventualmente nele existentes que possam influenciar na busca da verdade real.

Registre-se que o direito das partes à produção de provas não é absoluto, devendo tal pretensão passar, obrigatoriamente, pelo crivo do julgador, responsável por analisar sua relevância e necessidade no âmbito dos seus poderes instrutórios, forte no artigo 139, do Código de Processo Civil, aplicável, ao processo penal, conforme o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Significa dizer, o indeferimento de provas inúteis e meramente protelatórias é um dever imposto ao julgador, em observância a outro direito que assiste ao réu, também de estatura constitucional, como é o caso da duração razoável do processo.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

“HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Inteligência dos artigos 155, 251 e 400, § 1º, do CPP Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2266570-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021) (Sublinhado meu).

Portanto, considerando a suficiência do conjunto probatório dos autos para o escorreito julgamento da lide, impõe-se o indeferimento da diligência defensiva.

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 20), laudo de constatação provisória (fls. 24/27) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 205/207), com resultados positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; laudo das munições (fls. 214/217), que atestou o potencial lesivo; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O mesmo se pode dizer quanto à prova de autoria. Senão vejamos.

O policial militar Nilton Cesar Moreira da Silva contou que durante patrulhamento de rotina avistou o réu - já alvo de denúncias nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas -, em uma motocicleta, entregando ou recebendo algo em uma esquina. O acusado, ao ver a viatura policial, começou a fugir em alta velocidade por diversos bairros desta urbe, vindo a perdê-lo de vista, até que localiza-lo mais a frente descendo da moto e tentando disfarçar, enquanto outra pessoa pegou o capacete e entrou em uma casa. Ante o cenário, decidiu pela abordagem, ocasião em que localizou na posse do increpado, mais precisamente dentro de suas vestimentas, entorpecentes e munições de diversos calibres. De acordo com a testemunhas, várias pessoas tentaram dificultar as diligências policiais, inclusive, o próprio acusado, que ofereceu resistência. Questionado, disse que o réu era conhecido por gerenciar o tráfico na rua de sua casa, sendo difícil abordá-lo, pois sempre conseguia escapar das ações policiais, evadindo-se para dentro de sua casa, e contando com o apoio de familiares e populares para driblar o cerco policial. Por fim, esclareceu que o acusado foi abordado em uma rua paralela à de sua casa.

Seu companheiro de farda Zaqueu Siqueira Azarias apresentou narrativa semelhante. Acrescentou dizendo que o réu continua envolvido com o vil comércio, já que apontado recentemente, de maneira informal, por usuários de entorpecentes como o traficante atuante no local dos fatos. Disse que após o delito, ora julgado, realizou a prisão de outras pessoas no bairro, as quais lhe confienciaram estarem guardando entorpecentes para o acusado. Esclareceu que a pessoa que estaria recebendo ou entregando drogas para o acusado na data dos fatos acabou não sendo identificada, pois optaram em perseguir Lucas na ocasião. Indagado, afirmou era impossível conduzir as pessoas que dificultavam a abordagem, por serem muitas. Ao final, informou que, após os fatos, abordou o réu novamente em atitude suspeita, porém, o liberou pois Lucas possuía apenas dinheiro na oportunidade.

A testemunha Wellington Ricardo de Souza, amigo de infância de Lucas, contou que o réu lhe entregou a chave de sua motocicleta e o capacete, e disse que jogaria bola. Questionado, contou ter presenciado a abordagem do réu pela polícia, não observando se foram apreendidas drogas em seu poder.

A informante judicial Adriana Márcia de Souza afirmou ter presenciado toda a abordagem policial ao réu, e que nada de ilícito foi localizado em sua posse. Disse, ainda, que não havia ninguém dificultando a ação policial.

A testemunha Juvência Grilo contou que o réu foi preso e colocado na viatura policial na esquina de sua casa. Declarou que nada de ilícito foi apreendido com Lucas, e que os agentes da lei disseram que estavam conduzindo-o à delegacia por desacato. Disse que havia um "povo" agressivo, que confrontou os policiais militares, na tentativa de liberar o acusado, pois estes teriam o algemado mesmo

não sendo localizado nenhum ilícito com Lucas. De acordo com a depoente, quando os policiais militares chegaram ao local, por volta das 19:30h, estava varrendo a frente de sua casa, e assim pode ver a abordagem de Lucas, que estava acompanhado de "uns meninos" que jogariam bola. A testemunha afirmou que conhecia apenas uma das pessoas que acompanhavam o acusado naquela ocasião, no caso, a testemunha Wellington, que segurava um capacete em uma das mãos.

Já a testemunha Francielle Moreira Alves disse que não presenciou os fatos, e desconhecer o envolvimento do acusado com o narcotráfico.

Andreza Figueira do Nascimento, genitora do acusado, contou que ao chegar ao local dos fatos, já encontrou seu filho algemado. Disse que o policial "de cabelo grisalho" (Zaqueu), lhe disse que Lucas "estava limpo", e que ela poderia se dirigir à delegacia, pois este seria conduzido somente por desacato. Afirmou que ninguém presenciou os agentes públicos apreendendo ilícitos com o réu, o que teria deixado os populares revoltados com a ação policial. Disse que Lucas trabalha eventualmente como ajudante de pedreiro. Andreza declarou que instalou câmeras de segurança para evitar que policiais "forjassem" seu filho, e que depois disso, eles o abordaram, porém, não o conduziram à delegacia. Finalizando dizendo que seu filho não possui envolvimento com o vil comércio, e que é perseguido pelo policial militar Nilton.

O réu, ao seu turno, alegou inocência. Contou que, de fato, parou para dar informações a um transeunte e, na sequência, continuou a caminhar. Disse que chegou a perceber a viatura policial, porém, como não recebeu nenhuma ordem de parada, rumou até encontrar seus amigos para jogarem bola. Abordado juntamente com um amigo, este foi liberado imediatamente, enquanto os agentes da lei o prenderam. Afirmou ter ficado inconformado com a abordagem policial por não possuir nada de ilícito, e que não entende a razão para os policiais quererem prejudicá-lo. Disse já ter sido alvo de inúmeras outras abordagens pelos mesmos policiais que o prenderam, os quais ainda o agridem, quando não existem outras pessoas próximas. De acordo com o interrogando, devido a tal situação, sua família instalou câmeras de monitoramento em frente a sua casa, e depois disso, os mesmos agentes públicos lhe abordaram, mas o liberaram em seguida. Ao cabo de sua autodefesa, disse que não possui renda, sendo auxiliado por sua genitora.

Eis o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a versão defensiva apresenta incoerência e contradições com as demais provas do processo, notadamente, com a fala dos policiais militares, notando-se que sua única vertente é lançar dúvidas sobre a veracidade das declarações dos agentes públicos.

Aqueles que acompanham as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.P.R.A. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp

875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, como nas declarações de sua genitora; afinidade; ou mesmo amizade, caso das testemunhas e demais informantes judiciais; poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias, como expressamente comentado pelos agentes estatais neste caso.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Frise-se, neste ponto, que as testemunhas e o informante judicial ouvidos conheciam o réu e a sua família antes dos fatos, e são moradoras do mesmo bairro.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Pois bem. Como se viu, os agentes da lei foram enfáticos ao dizerem que os ilícitos foram apreendidos na posse do acusado, ao passo que, uma testemunha (Juvência Grilo), e dois informantes judiciais (Adriana e Wellington), asseveraram que presenciaram a abordagem, e que não visualizaram a apreensão de qualquer droga ou munição com Lucas.

Porém, ainda assim, há que se relativizar o que disseram Juvência e os informantes judiciais.

Afinal, não bastasse a contradição entre alguns pontos de seus depoimentos - perceba-se que, enquanto a testemunha confirmou a versão dos policiais, dizendo que populares tentaram retirar Lucas do interior da viatura; os informantes declararam que ninguém chegou a interferir diretamente na ação policial - não se exclui a possibilidade deles não terem visualizado a apreensão dos narcóticos e das munições, à luz da aglomeração de pessoas formada no local.

Registre-se que os vídeos juntados pela combativa defesa (fls. 213), com precariedade das imagens e áudio, apenas reproduzem cenas de policiais militares, viaturas, pessoas conversando, cachorro latindo etc, não permitindo sequer possível identificar os envolvidos, muito menos, o teor dos diálogos.

Assim, sem contar com suporte probatório idôneo, encampar a narrativa defensiva significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar as palavras dos próprios policiais, agentes que gozam de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse na incriminação de inocentes.

De mais a mais, o réu não demonstrou estratégia criada para incriminá-lo, nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) - OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS - PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA

QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Por fim, esclareço ser desnecessário para configuração do crime de tráfico de drogas que o agente seja flagrado em atos de mercancia, visto que a prática de qualquer uma das múltiplas ações previstas no tipo penal já é suficiente para tal fim, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, à luz da quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes (29 pinos de "cocaína"); das informações reveladas pelos policiais militares indicando o envolvimento pretérito do acusado com o narcotráfico; ou ainda, do comportamento nada usual de Lucas na ocasião, tentando escapar da ação policial.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Lado outro, com relação aos delitos da Lei de Armas atribuídos ao acusado, de rigor a redefinição da classificação de uma das condutas censuradas.

Decerto, imputa-se ao réu aos crimes dos artigos 14 e 16, caput, da Lei 10.826/03, em razão da conduta de portar 09 (nove) munições, de uso permitido, e 02 (duas) munições, calibre “9 mm”, à época, de uso restrito.

Contudo, com o advento da Lei 13.964/19, Decreto 9.847/19, Decreto 10.030/19 e Portaria 1.222/19, do Comando do Exército, as armas e munições de calibre “9 mm” deixaram de ser consideradas de uso restrito, motivo pelo qual a lei penal em branco, complementada pela portaria citada, deve retroagir para beneficiar o acusado, nos termos do artigo 2º, do Código Penal.

De fato, por se tratar de novatio legis in mellius, deve ser aplicada ao caso concreto. Logo, o réu será condenado por um único crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/03 (porte de arma de uso permitido), ressaltando-se que o laudo pericial de fls. 214/217 atestou que as munições eram aptas e foram disparadas, demonstrando o potencial lesivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

“(…) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Novatio legis in mellius. Decreto nº 9847/19 e Portaria 1.222/2019. Pistola de 9 mm. Arma de uso permitido. Penas reduzidas. Apelo parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0000523-57.2018.8.26.0559; Relator: Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"(...) PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Objetos devidamente periciados, conforme laudo acostado. Policiais militares que confirmaram a apreensão, no interior do quarto do acusado, de munições calibres 357 e 9mm. (...) NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. Decretos nºs 9.493/18 e 10.030/19 a revogarem o Decreto 3.665/00 que considerava as munições apreendidas como de uso restrito/proibido. Aplicação da Portaria nº 1.222/19 do Ministério da Defesa a considerá-las de uso permitido. Desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei 10.826/03. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0004998-78.2016.8.26.0445; Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).

Passo à dosimetria da pena.

a) Crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06:

O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, não lhe sendo desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais, já que a quantidade de narcóticos (18,12 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuídas em 29 pinos plásticos), malgrado exagerada para um simples usuário, não extrapola a culpabilidade normal à espécie.

Assim, fixo a basilar no piso legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornada definitiva por não existirem outras circunstâncias modificadoras.

O réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que as minúcias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito de tratar-se de primário e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

Primeiro, o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo para seu sustento, sequer apresentando qualquer ocupação lícita, ainda que estudantil.

Segundo, Lucas responde atualmente a outras ações penais, em trâmite neste mesmo Juízo (autos nºs 1527150-20.2018.8.26.0625, com condenação em primeiro grau de jurisdição, atualmente, em fase recursal; e 1500870-11.2019.8.26.0323, com denúncia recebida e mandado de prisão expedido em seu desfavor), sem contar sua condenação nestes autos, pelo crime de porte irregular de munição.

A propósito, informativo do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Terceiro, os policiais militares foram enfáticos em apontar o acusado como "gerente" do tráfico em seu bairro, informando o cabo Zaqueu, inclusive, que Lucas voltou a traficar após ganhar liberdade provisória neste feito por decisão da Superior Instância.

Tais circunstâncias, portanto, estão a indicar que Lucas é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo

Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Sabe-se que tal redutora destina-se apenas aquele que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

b) Crime do artigo 14, da Lei 10.826/03:

Como exposto anteriormente, o réu não possui maus antecedentes.

No entanto, cabe apontar a maior reprovabilidade da conduta, na medida em que foram apreendidas mais de uma munição de calibres diversos, de modo a incrementar o risco ao bem jurídico tutelado pelo tipo.

Portanto, estabeleço a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do piso, ou seja, em 02

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, aqui já em definitivo, por não existirem outras causas alteradoras.

Em se tratando de concurso material de delitos, as penas deverão ser somadas, resultando em uma pena total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 511 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, à luz do quantum de pena aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como do concurso material de crimes, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de medidas despenalizadoras.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para, nos termos do artigo 383, do CPP, desclassificando a conduta, a priori capitulada no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, condenar LUCAS FIGUEIRA DO NASCIMENTO DA SILVA RIZATO, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69, do CP, às penas totais de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, diária mínima.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que participou de todos atos processuais, após ser agraciado com a liberdade provisória obtida por meio de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça (fls. 107/114).

Não olvido do relato do policial militar Zaqueu indicando que Lucas retornou a prática do comércio espúrio, após ter sua liberdade restaurada. No entanto, considerando a precariedade da informação revelada pelo competente agente pública, vez que oriunda de terceira pessoa (usuário de drogas), entendo insuficiente para cassar-lhe tal direito.

Custas pelo vencido.

A propósito:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na

parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição. Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas.

Com relação ao celular apreendido (fls. 20), como nada fora produzido nos autos indicando o emprego dele no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverá ser revertido ao Funad; salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada a destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o mandado de prisão e, após cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA